



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

DEBIDO PROCESO/CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 29

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

DEBIDO PROCESO /SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO/ SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.

**EXTENSION DE GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO AL AMBITO ADMINISTRATIVO/
SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL**

La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo no implica, sin embargo, que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función pública. A pesar de la importancia que tiene para el orden constitucional la vigencia del debido proceso en todos los escenarios en los que el ciudadano puede ver afectados sus derechos por actuaciones públicas (sin importar de qué rama provienen), es necesario que la interpretación de las garantías que lo componen tome en consideración los principios que caracterizan cada escenario, así como las diferencias que existen entre ellos.¹

¹ Sentencia C-034/14

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2015-253
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 005 del 13 de marzo de 2015
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo confirma totalmente el fallo sancionatorio proferido el 21 de noviembre de 2016

FALLO NO. 005 DEL 13 DE MARZO DE 2017

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el sujeto procesal XXXXX XXXXX XXXXX en su condición de procesado, contra el fallo sancionatorio proferido por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias, el pasado 21 de noviembre de 2016, dentro del expediente disciplinario 1704-01 -2015-253.

COMPETENCIA

EL suscrito Director General (e) de la Unidad Administrativa Especial Agenda del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3o del Decreto 00985 de 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

- Los hechos que originaron la presente actuación disciplinaria fueron puestos en conocimiento de las Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, por la funcionaria XXXXX XXXXX, Directora Seccional de impuestos y Aduanas de Maicao, quien remitió el 27 de noviembre de 2014, el expediente aduanero radicado bajo el Nro. PF-2013-2013-3900676 DM, con el fin de establecer posibles irregularidades relacionadas con la configuración de un silencio administrativo positivo. Ver fl. 5 del c. o.
- A folio 113 del c. o., obra el auto calendado el 28 de enero de 2015, a través del cual la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales de la DIAN, dependencia que conoció inicialmente del caso, dispuso la apertura de indagación preliminar, en averiguación de responsables. Por conductas relacionadas con el silencio administrativo positivo "...que pudo acaecer dentro del expediente aduanero PF-2013-2013-3900676 a nombre de Ernesto Peña Velasco.
- En desarrollo de la indagación preliminar y con auto fechado el 16 de abril de 2015, se dispuso la vinculación como "indagado", del funcionario XXXXX XXXXX, quien se notificó personalmente de la decisión de apertura de indagación preliminar y de la orden de vinculación, el 20 de abril de 2015. Ver fls. 126 a 147 del c. o.
- Con fecha 10 de agosto de 2015 el funcionario instructor de conocimiento ordenó abrir investigación disciplinaria en contra de los funcionarios XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, quienes se notificaron personalmente de la decisión los días 24 y 26 de agosto de 2015, respectivamente. Ver fls. 206 a 228 del c. o.
- El 9 de octubre de 2015 el Subdirector de Gestión de Control Disciplinario interno de la DIAN ordenó la remisión del expediente disciplinario 213-304-2015-16, ante esta U.A.E.

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

Agencia ITRC, por competencia, al considerar que los hechos objeto de investigación constituían un posible atentado contra la fe pública, por la alteración de un documento, tal como expresamente lo refirió una de las funcionarias implicadas, en su diligencia de versión. Simultáneamente se ordenó la remisión del expediente original aduanero, sobre el cual se perpetró el hecho objeto de investigación. Ver fls. 239 a 242 del c. o.

- Recibido el expediente disciplinario en esta U.A.E., la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias avocó el conocimiento del asunto, mediante decisión signada el 20 de noviembre de Ver fls. 360 y 361 dele. o.

- Mediante decisiones signadas los días 24 de febrero y 17 de marzo de 2016, el funcionario instructor comisionado decretó la práctica de pruebas tendientes al perfeccionamiento de la instrucción. Ver fls. 364 y 396 del c. o.

-. Con anterioridad a estas últimas actuaciones, se recibió y cursó ante la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, la indagación preliminar 213-303-2014-293, remitida por la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, con auto del 30 de octubre de 2014. En esta actuación se avocó el conocimiento el 27 de enero de 2015; y se ordenó apertura de investigación disciplinaria contra el mismo funcionario XXXXX XXXXX, quien se notificó personalmente de la decisión el 15 de abril de 2015.

- Con fecha 13 de abril de 2016, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias dispuso incorporar el expediente número 1704-01-2015-009 al expediente número 1704-01-2015-253, bajo la siguiente consideración: "...se advierte que la conducta por la que se está investigando al señor XXXXX XXXXX, guardan relación pues en ambos casos los señalamientos refieren a situaciones de presunta adulteración de las fechas de recibo de los documentos recursos de reconsideración incoados por las sociedades XXXXX. Y XXXXX.

- El 29 de abril de 2016, el funcionario instructor de conocimiento dispuso el cierre de la etapa investigativa unificada en los dos expedientes integrados. Esta decisión se notificó a los sujetos procesales el 22 de junio de 2016.

- El mérito de la actuación disciplinaria unificada, fue evaluado por el operador jurídico de primer grado, mediante decisión calendada el 27 de julio de 2016, en la cual se formularon cargos en contra del funcionario XXXXX XXXXX, como presunto autor responsable de la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, O relacionada con la realización objetiva de la conducta delictiva dolosa, consagrada en los artículos 287 y 289 de la Ley 599 de 2000 C. de P.P. En la misma decisión se ordenó la terminación y el archivo definitivo, en favor de la disciplinada XXXXX XXXXX. El auto acusatorio se notificó personalmente a los procesados XXXXX XXXXX Y XXXXX XXXXX, respectivamente, los días 18 y 24 de agosto de 2016. Ver fls 664 a 695 del c. o.

- Con fecha 19 de octubre de 2016, el funcionario de conocimiento corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión. Ver fl. 699 del c. o. El procesado. XXXXX XXXXX se notificó personalmente el 24 de octubre de 2016. (Ver fl. 704 del c. o.)

- El 21 de noviembre de 2016 el fallador de instancia declaró la responsabilidad disciplinaria del procesado, por la conducta objeto de acusación. Como consecuencia, impuso como sanción destitución e inhabilidad general, por el término de 12 años. Esta decisión se notificó personalmente al sancionado el 14 de diciembre de 2016. Ver fls. 709 a 725 del c. o.

14 - El 19 de diciembre de 2016, el servidor procesado presentó y sustentó el recurso de apelación, contra la decisión de instancia; siendo concedida la impugnación, ante este despacho, en el efecto suspensivo, el 27 de diciembre de la misma anualidad. Las

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

diligencias se recibieron en este despacho ad que, el 29 de diciembre del año anterior, para desatar la alzada. Ver fls. 726 a 747 del c. o.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

Los primeros títulos del fallo de instancia, contienen un resumen referente a la identidad del procesado, los hechos objeto de investigación y el cargo formulado.

Es a partir del título señalado bajo el numeral 5, que el autor del fallo inició la referencia y análisis propio de las pruebas soporte de su decisión. Inicialmente, la valoración probatoria se centró en estudiar la recepción y trámite dado a los recursos de reconsideración presentados dentro de los expedientes aduaneros de definición de situación jurídica radicados: 2013 2013 3900676 y 2013 20133900561, adelantados, respectivamente, contra los contribuyentes XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX y XXXXX. Para este efecto se acudió a las pruebas documentales y de inspección administrativa, practicadas durante el desarrollo de la actuación. Simultáneamente fueron valorados los testimonios de XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX.

El título 6 del fallo recurrido contiene un recuento de los argumentos defensivos del disciplinado, presentados en el proceso, en sus diferentes diligencias de versión y alegatos de conclusión. Al respecto se resaltó la idea planteada por el procesado, de no haber recibido el recurso de reconsideración presentado por el representante legal de la firma XXXXX XXXXX. Adicionalmente su planteamiento exculpatario basado en el hecho de no incurrir en ninguna falta disciplinaria, por no haber causado daño a los intereses patrimoniales del Estado. Finalmente se registró la manifestación del funcionario implicado, en la que rechazó las falsedades objeto de acusación, aduciendo: "...la falsedad en documento público Y falsedad en documento privado no se estructuran porque los medios alterados no fueron utilizados como prueba, situación que transforma en inocuos los presuntos cambios introducidos al no menoscabarse bien jurídico alguno.

En el numeral 7, "CONSIDERACIONES DE LA INSTANCIA", el fallador a quo hizo una reseña de los elementos que estructuran la falta disciplinaria, tales como la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, argumentando con jurisprudencia que, los mismos deben estar soportados probatoriamente en el proceso.

Al abordar el requisito sustancial de certeza en la comisión de la falta, el operador de primer grado empezó por transcribir los tipos penales que integraron o complementaron la conducta disciplinaria que fue objeto de acusación. A continuación, reiteró, en qué consistieron las mutaciones o alteraciones en la originalidad de los documentos públicos y privados, tantas veces mencionados, atribuibles al servidor acusado; de quien se dijo, no hizo ninguna discusión al respecto, limitándose en alegar que los tipos penales no tenían prosperidad, por no haberse utilizado como pruebas los documentos objeto de falsificación. Adicionalmente a la demostración de las variaciones aludidas, realizadas sobre los documentos igualmente conocidos, el fallador aseveró que dichos comportamientos fueron cometidos, por el procesado, con ocasión del cargo desempeñado, al desplegar la función de proyectar los actos administrativos resolutorios de los recursos de reconsideración formulados en los expedientes aduaneros.

Concluyendo este acápite, las consideraciones de la instancia estuvieron orientadas en demostrar la certeza en la responsabilidad y la forma de culpabilidad del servidor procesado. Al respecto, el autor del fallo refirió nuevamente las pruebas documentales (planillas de entrega, correos y copias de los expedientes), las cuales, junto con las pruebas testimoniales, corroboraron al despacho el recibo de los dos recursos de reconsideración por parte del procesado y su actuar funcional, al ser el encargado de tramitar y proyectar la respuesta jurídica a los actos de impugnación. Bajo esta premisa, para la instancia es claro que fue el procesado quien alteró las constancias de recibido y los sellos de notificación, pues solo a él le convenía tal proceder, para evitar que dichas

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

actuaciones se vieran afectadas con una posible declaratoria de silencio administrativo positivo. Haciendo referencia a las condiciones propias de formación profesional y experiencia del servidor implicado, la calificación de su comportamiento se confirmó como dolosa, dentro del fallo impugnado.

En lo que atañe a la ilicitud sustancial del comportamiento reprochado al procesado, expresó el fallador en el numeral 7.3 de su sentencia, lo siguiente: "...se afectó el deber funcional sin justificación alguna, ...porque al realizar objetivamente conductas violatorias del bien jurídico de la fe pública se vulneraron principios de transparencia, legalidad y honradez por encubrir una situación administrativa común al ejercicio de la actividad pública.

A partir del numeral 7.4 de sus consideraciones, el operador jurídico de instancia realizó el juicio de dosificación e imposición de la sanción a imponer al procesado. Con referencia a la normatividad pertinente y atendiendo el hecho de encontrarnos ante una falta gravísima dolosa, se concluyó que la sanción a imponer no podría ser otra que destitución e inhabilitación general por doce (12) años. Como criterios, en favor del sancionado, se consideraron la ausencia de antecedentes disciplinarios y no atribuir responsabilidad a un tercero. En contra del sancionado se valoró, la reiteración de su conducta, en dos procesos aduaneros, y su actuar doloso.

En los últimos tres párrafos de los considerandos y como respuesta a los alegatos de conclusión, expresó el fallador a quo lo siguiente:

..No hay discusión en que ningún interés le asistía en favorecer a los infractores aduaneros, a fin de cuentas, igual no había forma de beneficiarlos, dado que nunca demostraron el legal ingreso de la mercancía ni estaban en posición de alegar un silencio administrativo a su favor.

"...Ahora, si bien desde el punto patrimonial no se afectó el Estado, diferente ocurre desde el ámbito funcional en cuanto a la legalidad y transparencia de su actuar, porque como se indicó en el acápite pertinente fueron varios los principios de la actividad pública vulnerados con su actuar. //

"...Resalta la Subdirección el compromiso del disciplinado con la preservación del orden legal, pero no puede ser pasiva ante los hechos que concitaron su atención en los procesos acumulados, habida cuenta que con ellos igual se burló la confianza de la entonces directora seccional, haciéndole creer estaba resolviendo en término los recursos de reconsideración, cuando la realidad era que el término fue superado y como medio para ocultarlo se recurrió al ardid adulterando documentos obrantes en los expedientes,

"...Finalmente contrario a lo señalado por el disciplinado, la Subdirección encuentra que los documentos alterados si fueron usados en su oportunidad, precisamente para inducir en error a quienes finalmente actuaron en los expedientes, por lo que se cumplen a satisfacción todos los elementos de las conductas penales cuya realización objetiva se imputó, demostró y por las que ahora se sanciona. Ahora bien, el simple hecho de dejar las piezas alteradas en los procesos aduaneros implica de por sí su uso, ...por lo que no se emitirá sanción favorable alguna..."

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

En su oportunidad, el sujeto procesal disciplinado impugnó el fallo de instancia, presentando un variado grupo de ideas o argumentos de sustentación de su apelación, que trataremos de condensar de la siguiente manera:

1.- En los tres primeros folios del escrito de sustentación, y bajo el título de "FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO", el recurrente hizo un resumen del acontecer fáctico y de algunos antecedentes procesales, para concluir con las siguientes

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

aseveraciones: "...En este caso manifiesto no haber incurrido en falta gravísima alguna tal y como lo señala el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 puesto que en el presente caso y en mi vida profesional como servidor público no he estado involucrado ni tengo antecedentes en delitos contemplados contra la administración pública, ni por corrupción, concusión o prevaricato.

En forma reiterativa, resaltó el impugnante su carencia de antecedentes penales o disciplinarios; la ausencia de detrimento patrimonial para el Estado, dentro de los hechos objeto de acusación; y "...no tener interés en proferir una decisión contraria a derecho ni vulnerar el derecho a la defensa de los usuarios que en ambos casos fue confirmar una decisión de fondo a favor de la Nación ya que se trataba de mercancías que habían ingresado a territorio aduanero nacional sin estar amparada en documentos legales.

2 - A partir del folio 730, y hasta el folio 736 del c o., la sustentación del recurso contiene, bajo el título "EL TIPO EN LOS DELITOS DOLOSOS", un amplio estudio del dolo genérico; intelectual o cognoscitivo; directo, eventual; sus distinciones con la culpa consciente; los elementos subjetivos del injusto; los delitos de intención y tendencia. Concluyendo este acápite el impugnante incluyó algunas de las siguientes frases: "...no se configuran los presupuestos para establecer mi conducta como dolosa;En la presente investigación se me está endilgando la responsabilidad objetiva de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen el proceso disciplinario, es decir que según ustedes mi conducta se adecuó al tipo señalado como falta gravísima y sancionable a título de dolo porque se cometió en razón, con ocasión, o como consecuencia de mi función o cargo y abusando del mismo. En la presente investigación no hay prueba fehaciente que permita determinar que yo fui el agente determinante de los hechos materia de investigación, es decir si no hay una descripción típica de mi conducta menos se me puede atribuir una sanción por demás no ajustada a derecho y violando todos los preceptos legales consagrados en la Constitución Política puesto que hay dudas procesales y ausencia de elementos de juicio que no se han resuelto.

- Desde el último párrafo del folio 736, los argumentos de sustentación del apelante reclamaron la nulidad del fallo apelado, con los siguientes argumentos: "...se encuentra incurso dentro de las nulidades señaladas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734/2002 ya que se me violaron el derecho a la defensa al no existir pruebas que demuestren el dolo del comportamiento objeto de reproche, ni mucho menos la certeza de la falta, tal como lo dispone el artículo 142 de la Ley 734 de 2002. En la presente investigación se violaron todos los principios de igualdad y legalidad, ...Hay una clara violación al debido proceso y derecho de defensa contemplado en el artículo 29 de la C.P. y en el artículo 60 de la Ley 734 de 2002 por la ausencia de pruebas demostrativas del dolo como elemento esencial en la tipificación de la falsedad y como requisito estructurante de culpabilidad dentro del proceso de sanción disciplinaria. Es decir, se debe dar aplicación de la causal sexta de exclusión de responsabilidad disciplinaria por haber actuado con la convicción errada e invencible de que mi conducta no constituye falta disciplinaria. Ver numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. ...De otra parte se le debe dar aplicación al artículo 88 del C.P.A. presumiendo la legalidad de las resoluciones (Documentos Públicos) que resolvieron sendos recursos de reconsideración toda vez que los mismos no han sido anulados por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por esta razón el fallo de primera instancia proferido estaría violando el principio de legalidad que cubre las mencionadas resoluciones así como el principio de legalidad en materia Disciplinaria pues no tiene competencia el operador disciplinario para evaluar un tema técnico asumiendo funciones de Juez natural...

- Con el título "... ¿Cuándo se tipifica el delito de falsificación de documento privado?", el autor del recurso reiteró su planteamiento expuesto en los alegatos de conclusión, al afirmar que la estructuración del delito aludido, tiene como requisito esencial, la utilización del documento falsificado, so pena de que la pretendida falsedad resulte inocua. Como complemento de su dicho el impugnante hizo transcripción de una tesis jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte suprema de Justicia, sobre el delito de falsedad.

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

5- Continuando con sus razonamientos el autor del recurso transcribió la Sentencia T-1263 del en la cual la Corte Constitucional, presenta algunos postulados sobre el debido proceso disciplinario. Como desarrollo de esta sentencia el apelante hizo algunos señalamientos genéricos, sobre lo que constituye la aplicación del principio general de derecho denominado "in dubio pro reo o in dubio pro disciplinado. Adicionalmente criticó la calificación de gravísima que se le dio a la falta objeto de reproche, concluyendo: "...Se evidencia que la imposición de sanción destitución no está acorde con los límites que señala el artículo 44 de la Ley 734 de 2002. En los dos últimos párrafos de este grupo de argumentos, el recurrente hizo reiteración a tres ideas ya conocidas: su carencia de antecedentes disciplinarios; no haber producido detrimento patrimonial al Estado con su comportamiento; El hecho de no haber sido anulados por el Contencioso, los autos que resolvieron los recursos de reconsideración.

- En el penúltimo título del escrito sustentatorio, el Sujeto procesal apelante requirió a esta instancia "...formular las siguientes PRUEBAS...:

- "...Contrainterrogatorio al señor XXXXX XXXXX...en calidad de representante de XXXXX XXXXX,

- "...Contrainterrogatorio al señor Jairo Armando Poveda Para que manifieste como fue el trámite para la entrega del documento de recurso de reconsideración ante la Dirección Seccional Maicao...".

- "Contrainterrogatorio a la funcionaria de la Seccional Maicao XXXXX XXXXX ... a efectos de determinar dentro de la presente investigación cómo fue el trámite de recepción de los recursos recibidos y su posterior entrega al funcionario competente,

- Oficiar a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao en cabeza del señor Director XXXXX XXXXX para que certifique si dentro de los expedientes ... fue decretado el silencio administrativo positivo ... determinar si hubo detrimento patrimonial del estado...."

- Oficiar a la funcionaria XXXXX XXXXX en su calidad de Jefe de la División de Gestión administrativa y Financiera para que certifique la situación de las mercancías dentro de los expedientes ... es decir si fueron destruidas o donadas y a través de qué resoluciones con el fin de establecer a qué obedeció su decomiso a favor de la Nación y determinar si hubo o no detrimento patrimonial del estado.

- "...Solicito la ampliación de mi versión libre que permita exponer los argumentos necesarios que no se debatieron en el proceso disciplinario como la ausencia de pruebas de oficio dejadas de practicar las cuales son conducentes y pertinentes para demostrar mi inocencia dentro de la presente investigación....".

- Que se dictamine por un perito competente la autenticidad de un documento privado en cuanto a su contenido y a su grafología, en este caso el escrito del recurso de reconsideración presentado por el señor XXXXX contra la resolución del expediente DM-20132013-3900676, ya que se considera una prueba idónea para demostrar su presunta falsedad.

- "...Que se determine por un perito competente la autenticidad de un documento público en cuanto a su contenido y a su grafología, en este caso la resolución número 00049 de fecha 11/02/2014 proferida y firmada por la funcionaria encargada para el momento de los hechos Yidelma Iguarán Tromp ...ya que se considera una prueba idónea para demostrar su presunta falsedad.

6.8-"...Que se determine por un perito competente la autenticidad de un documento público en cuanto a su contenido y a su grafología, en este caso la resolución número 00081 de

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

fecha 5/03/2014 proferida y firmada por la funcionaria encargada para el momento de los hechos Yidelma Iguarán Tromp ... ya que se considera una prueba idónea para demostrar su presunta falsedad.

Con base en todo lo anterior y como petición especial, solicitó el recurrente revocar integralmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, absolverlo de toda responsabilidad.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar a la impugnante que de conformidad con la previsión legal consagrada en el párrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

"...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

Previo a entrar a decidir sobre el fondo del asunto, entrará el Despacho pronunciarse sobre las peticiones de nulidad y las solicitudes de pruebas elevadas por el procesado ante esta instancia procesal, en el momento mismo de sustentar el recurso de apelación.

DE LAS NULIDADES:

En el presente caso, hallándonos ante la oportunidad procesal destinada para resolver en segunda instancia la actuación, nos encontramos ante la imposibilidad jurídica de ver próspera la solicitud de una nulidad alegada por el recurrente, toda vez que, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, se establece como requisito de procedibilidad etapas específicas para la formulación de la petición de invalidez, veamos:

"La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten". es que la solicitud de nulidad elevada por el servidor procesado, quien ostenta la condición de profesional del derecho, además de realizarse dentro del recurso de apelación, se impetró sin realizar una determinación o concreción frente a las causales invocadas y a los fundamentos sustento de la pretensión.

Aseveró el recurrente que el fallo impugnado está incurso en las causales 2 y 3 del artículo 143 del D. U., ya que en su concepto no existen pruebas que demuestren el dolo del comportamiento que se le reprocha, ni mucho menos la certeza en la comisión de la falta.

Pese a lo abstracto o indeterminado de esta afirmación, está precisamente el procesado cumpliendo con una de las posibilidades de su defensa, al ejercer su derecho de contradicción. Revisado el proceso, observa este despacho que durante el trámite de la instancia se respetaron siempre los derechos y facultades del investigado, quien conoció las decisiones que desarrollaron la actuación, y, a pesar de tener la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas en su versión o memorial de descargos, se abstuvo de obrar de esta manera, reclamando ahora una mayor instrucción probatoria por parte del Director del proceso. Debe acotarse igualmente, que el hecho de no compartir el análisis probatorio realizado por el fallador a quo, no significa que no se hubieren decretado, practicado y valorado unas pruebas concretas, las cuales sirvieron de soporte a la decisión sancionatoria que ahora se impugna. Sin embargo, los variados elementos probatorios documentales, testimoniales y de inspecciones administrativas, que fueron objeto de estudio y análisis en la decisión de instancia, no merecieron el más mínimo comentario por el apelante, quien simplemente optó por desconocer ese ejercicio probatorio, para concluir de manera infundada afirmando que se omitió cumplir con el requisito probatorio para sancionar.

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

Un ataque planteado de esta manera no está llamado a prosperar pues, al procesado le cabe la carga de argumentar de manera suficiente todas y cada una de las supuestas falencias que exhibe el proceso. No es pues, efectuando sindicaciones de ilegalidad y de omisiones probatorias, para lo cual simplemente asumió una postura de desconocimiento e indiferencia, voluntaria, frente al trabajo de análisis y valoración realizado por el fallador de primer grado.

Nótese que no existe ninguna lógica en la argumentación del recurrente, toda vez que al aducir la presunta vulneración de su defensa, no expresó en qué aspectos fue transgredido este derecho. Lo mismo sucedió con las supuestas irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso, tampoco fueron dilucidadas por el memorialista, pretendiendo confundir este aspecto con las inexistentes omisiones probatorias que mencionó en su recurso. Finalmente, terminó su solicitud de invalidez, reclamando de manera improcedente la aplicación del artículo 88 del C. DE P.C.A., junto con la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el numeral 6 del artículo 28 del C.U., siendo estas manifestaciones defensivas totalmente novedosas para las resultas del proceso, pues ninguna de las salidas procesales del servidor implicado, fueron alegadas como argumentos exculpatorios.

De lo anterior, se observa, que en la petición de nulidad no hay coherencia ni fundamentación; razón por la cual no son de recibo las argumentaciones expuestas y en consecuencia, las causales de nulidad no están llamada a prosperar.

DE LAS PRUEBAS:

El Despacho estima que la petición de pruebas en esta instancia, resulta improcedente, toda vez que la actuación disciplinaria constituye una unidad, cuya actividad se desarrolla de manera secuencia, es decir, tiene etapas o fases previamente definidas y términos preclusivos. Por lo que en cada etapa se deben surtir las actuaciones procesales establecidas para cada una de las partes que intervienen en el proceso. Dentro del marco jurídico de ritualidades preestablecidas legalmente, se definen, entre otros asuntos, el momento a partir del cual el procesado puede acceder a las diligencias que contra él se adelantan, y solicitar pruebas y controvertirlas.

Ahora bien, respecto a la oportunidad para la solicitud de pruebas, el artículo 138 de la Ley 734 de 2002, indica que los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas, a partir de momento en que tengan acceso, a la actuación disciplinaria; igualmente, los artículos 166 y 168 ibídem, establecen que durante la fase de descargos, el acusado puede aportar y controvertir pruebas las cuales serán decretadas y practicadas de acuerdo a los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Todo lo anterior, permite concluir que la facultad de solicitar y controvertir las pruebas está ampliamente garantizada por la Constitución y la Ley, puesto que tal prerrogativa se puede ejercer desde el momento en que tengan acceso a la actuación, hasta cuando se presente el memorial de descargos.

Sobre la petición de las pruebas en segunda instancia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 171 de la mencionada ley, se limitó la práctica de las mismas, a la discrecionalidad del operador disciplinario, otorgándole una facultad oficiosa, es decir restringiendo la posibilidad de que sean solicitadas por el disciplinado.

El tema de solicitud de pruebas en la segunda instancia ha sido tratado por la Corte Constitucional, en sentencia 181 de 2002, donde se enseñó lo siguiente:

"La disposición analizada en esta oportunidad restringe la posibilidad de solicitar pruebas durante la segunda instancia del proceso disciplinario, dejando a discreción de la autoridad disciplinaria la facultad de ordenarlas de oficio. Vistos el contenido de la normas que fueron citadas anteriormente y la generosa gama de posibilidades que aquella confiere

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

al imputado para solicitar pruebas del proceso disciplinario, esta Corte no encuentra que la restricción impuesta por la norma demandada atente contra el derecho de defensa del disciplinado.

En efecto, aunque resulte redundante con el recuento dispositivo citado, la Ley 200 permite que hasta el momento de surtirse el fallo de primera instancia, el inculpado o su representante, soliciten pruebas a la autoridad competente. Esta garantía busca que la parte investigada demuestre la veracidad de sus afirmaciones y con ello desvirtúe los cargos formulados en su contra durante la instrucción.

Por el contrario, la discusión que por virtud del recurso de apelación, tiene lugar en la segunda instancia no está encaminada a probar o desvirtuar los hechos que promueven la apertura de la investigación, disciplinaria y sobre los cuales recae la formulación de los cargos, sino a controvertir la apreciación que de los mismos ha hecho el funcionario de primera instancia...".

Conforme a todo lo expuesto, el Despacho negará la solicitud de pruebas presentada por el procesado, por ser improcedentes en esta fase del proceso disciplinario, aclarando de paso que tampoco hará uso de la facultad oficiosa que establece la ley, por cuanto los medios demostrativos requeridos en el escrito de apelación, son inconducentes, impertinentes y manifiestamente superfluos o innecesarios, para determinar la responsabilidad disciplinaria que se le imputa al sancionado. Nótese que el régimen probatorio disciplinario actual, no permite ningún tipo de contrainterrogatorios o careos como sucedía en otros tiempos y bajo otras regulaciones. Incluso, entendiéndose que lo que pretendía el procesado era intentar unas ampliaciones de testimonios, para controvertir a los declarantes, debe afirmar el despacho que dichas posibilidades ya fenecieron para el sujeto procesal petente, quien tuvo la oportunidad de hacerlo en desarrollo del juicio. Adicionalmente observa esta instancia que en forma totalmente inconducente, frente al objeto de prueba de la actuación, el procesado insiste en su intención de demostrar que no hubo detrimento patrimonial del estado, hecho que fue tenido en cuenta por el fallador a quo, únicamente y en forma acertada, para atenuar la dosificación de la pena.

Igualmente debe hacerse notar al servidor implicado que en este proceso disciplinario no fue objeto de investigación y sanción la presunta legalidad o no, de las decisiones de decomiso de mercancías.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Habiendo definido el tema de las peticiones de nulidad y solicitudes probatorias, resulta imperioso explicar al sujeto procesal impugnante, en qué consiste la actividad de sustentar un recurso de apelación, toda vez que en el caso sub judice, nos encontramos ante un escrito de impugnación que solamente ofrece una multiplicidad de argumentos, carentes de concreción o determinación, frente a lo que verdaderamente debe entenderse como una actividad de contradicción de una decisión sancionatoria.

Al respecto ha sostenido la jurisprudencia lo siguiente:

Así como se exige que las providencias judiciales (autos y sentencias) y en general los actos de la administración, en tratándose de determinaciones adoptadas a propósito de los trámites disciplinarios, sean motivadas, coherentes y lógicas, así mismo se exige que los recursos sean sustentados en forma clara, concreta, coherente y lógica.

Lo anterior nos enseña que el memorial donde se interpone el recurso debe contener un desarrollo cuya premisa mayor es el fallo o auto a controvertir, la menor, la verdad en los términos concebidos por el recurrente, y la conclusión, que es la petición de reforma o revocatoria. Argumentos que, si bien no deben ser ampulosos, no por ello podrán ser

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

carentes de rigorismo lógico. La libertad que se plantea para el memorialista radica en la forma de expresión, en su extensión, pero no en la estructura conceptual del argumento.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó: "...No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de esas razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...",

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado: "...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa "combatir, contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa providencia recurrida, a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación".

Agrega tajantemente la misma corporación : "...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como "si hay prueba de los hechos", "no están demostrados los hechos", u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado" (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

En ese orden de ideas, es necesario entender, que quien apela debe preocuparse por el contenido de la decisión judicial que ataca, analizarla, revisar cual es el error en el que incurre, que normas de derecho resultan violadas con ese error, expresar claramente cuál es la trascendencia de ese error y cual el efecto jurídico que surge al ser corregido por el superior, para concluir con la pretensión de revocatoria o modificación de la providencia impugnada, circunstancias o presupuestos ausentes en el caso a examen, en donde el apelante tan solo reiteró algunos limitados argumentos de sus alegaciones finales, pero dejó de lado la tarea argumentativa necesaria para que el ad que conozca las razones específicas de la inconformidad del citado para con la determinación de primera instancia.

En efecto, en el presente evento es claro que si bien el procesado XXXXX XXXXX, estando dentro de la oportunidad legal, expresó su intención de impugnar el fallo, omitió cumplir con la carga procesal que le imponía el deber de señalar los motivos, las razones de hecho o de derecho que lo llevan a discrepar con la determinación del a quo, vale decir, no sustentó en forma debida el recurso de alzada incoado contra el fallo sancionatorio fechado el 21 de noviembre de 2016.

Ahora bien, el Consejo de Estado¹, en materia de competencia del superior con ocasión del recurso de apelación ha sostenido:

"...En este orden de ideas resulta claro que para el juez de segunda instancia el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de la congruencia de la sentencia, de acuerdo con el cual "las

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad que: 'tantum devolutum quantum appellatum'"

La misma Corporación en pronunciamientos recientes² ha precisado respecto a la forma de sustentar el recurso de apelación:

Sección Tercera, sentencia de 10 de Junio de 2009. Exp 16985

zVer entre otras sentencias de la Sección Tercera: Sentencia de 14 de abril de 2010. Exp 18.115; Sentencia de 21 de febrero de 2011. Exp 17721."...De tal manera que si en el escrito presentado ante eí ad-quem a modo de sustentación del recurso de apelación interpuesto no se adujo argumento alguno tendiente a desvirtuar la presunción de acierto v corrección que recae sobre la sentencia de primera instancia, carece el juzgador de segunda instancia de razones para revisar dicho fallo, pues se reitera que el marco de su decisión dentro dei ámbito del recurso de apelación está dado por esas argumentaciones v elementos de juicio planteados por el recurrente en la sustentación v que constituyen por lo tanto los medios de convicción por él utilizados respecto de la existencia de errores en la decisión cuestionada: obviamente, si no se esgrime crítica alguna respecto de ia sentencia objeto del recurso de apelación, desconoce el ad-quem cuáles son esos errores que el recurrente considera presentes en dicha providencia, que por lo tanto deberá permanecer incólume..."

Significa todo lo anterior que resulta indispensable, al interponer el recurso de apelación en contra de una determinación, sustentarlo en debida forma, lo cual equivale a exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sirven de fundamento a la discrepancia del recurrente para con la decisión del operador disciplinario de primera instancia, contentiva del fallo sancionatorio proferido en las presentes diligencias disciplinarias.

De conformidad con lo expuesto, es claro que el recurrente en el sub lite no cumplió con la carga procesal que pendía sobre él, pues simplemente limitó su exigua argumentación en reiterar, tal como lo hizo en sus alegatos conclusivos.

Nótese que el apelante mantuvo huérfana su "presunta sustentación", frente a las razones puntuales de hecho y/o de derecho, que lo motivaron a apartarse de lo resuelto por el a quo.

En la sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, la Corte Constitucional, declaró la exequibilidad de la obligación legal de "sustentar un recurso de apelación" y entre otras cosas dijo:

"...Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve ios motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso..

Es lógico concluir que en este evento, EL DEBIDO PROCESO IMPUGNATORIO, del cual, la sustentación debida es una faceta simplemente, resultaría menoscabado en el evento de que el despacho emita decisión de fondo en segunda instancia, por carencia de competencia, en tanto no está legitimado para emitir pronunciamiento porque el recurso no fue debidamente sustentado. Por eso, es que la figura de la "sustentación debida" no es simplemente, una carga argumentativa para el recurrente, sino, también, una carga jurídica para quien decide, en la medida en que se entienda, que el superior antes de definir un recurso, debe manifestar expresamente su competencia para ello.

En ese orden de ideas, lo procedente es rechazar el recurso de apelación interpuesto porque resulta imposible pronunciarse en relación con la impugnación presentada por el

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

procesado XXXXX XXXXX, por carecer de los criterios fácticos y jurídicos que contradigan o refuten la decisión del a-quo, presupuesto ineludible para que este despacho adquiriera competencia y legitimidad para desatar la alzada propuesta contra el fallo sancionatorio calendarado el 21 de noviembre de 2016.

Nótese cómo la generalidad, indeterminación y abstracción del recurso, se hace evidente en los numerales 1, 2 y 5 precedentes, donde se intentaron resumir las razones de sustentación del recurrente. En dichos párrafos el autor del recurso acude a frases tales como:

"...manifiesto no haber incurrido en falta gravísima alguna tal y como lo señala el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 puesto que en el presente caso y en mi vida profesional como servidor público no he estado involucrado ni tengo antecedentes en delitos contemplados contra la administración pública, ni por corrupción, concusión o prevaricato..."

"...no se configuran los presupuestos para establecer mi conducta como dolosa;..."

"...En la presente investigación se me está endilgando la responsabilidad objetiva de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen el proceso disciplinario, es decir que según ustedes mi conducta se adecuó al tipo señalado como falta gravísima y sancionable a título de dolo porque se cometió en razón, con ocasión, o como consecuencia de mi función o cargo y abusando del mismo. //

"...En la presente investigación no hay prueba fehaciente que permita determinar que yo fui el agente determinante de los hechos materia de investigación, es decir si no hay una descripción típica de mi conducta menos se me puede atribuir una sanción por demás no ajustada a derecho y violando todos los preceptos legales consagrados en la Constitución Política puesto que hay dudas procesales y ausencia de elementos de juicio que no se han resuelto".

A pesar de que el recurrente utilizó este tipo de afirmaciones abstractas, se abstuvo por completo de analizar la postura que, sobre temas puntuales como la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, realizó el operador jurídico de primer grado.

De la misma forma, el apelante optó por reiterar, sin mayores argumentos, los planteamientos sobre su carencia de antecedentes disciplinarios y sobre el hecho de no haber afectado el patrimonio estatal, sin observar que esos tópicos fueron evaluados por el fallador a quo a! atenuar su sanción.

Otra de las tesis del recurrente que se mantuvieron en ja simple reiteración, durante la apelación; tiene que ver con su afirmación de no haber tenido ningún interés para favorecer o no a los sujetos procesales interesados en la interposición de los recursos de reconsideración. La posición del a quo al respecto fue clara, a! expresar, en varios considerandos, que efectivamente la alteración o modificación de los documentos aludidos, solo le interesaba al profesional implicado, como único responsable de tramitar y proyectar los actos de impugnación, dentro de los términos temporales que fueron objeto de modificación o falsificación. Situación que a la postre fue advertida por los superiores funcionales, dando lugar a esta actuación disciplinaria. Esta conclusión del fallador de instancia pasó inadvertida para el procesado, quien simplemente reiteró su planteamiento, sin ejercer contradicción.

Es importante resaltar que este despacho respalda el análisis probatorio realizado por el fallador a quo, sobre pruebas documentales, testimoniales y de inspecciones administrativas, acervo que en su totalidad conformó el requisito probatorio exigido en el artículo 142 del C. D.U. Frente a esa evaluación probatoria, que no fue objeto de contradicción por parte del recurrente, debe rechazarse la simple afirmación genérica que realizó el procesado en su recurso, cuando aseveró que no existieron pruebas soporte de la decisión de primer grado.

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

Finalmente, una última idea que simplemente fue objeto de reiteración en el recurso, sin hacer pronunciamiento alguno frente a las consideraciones de la instancia, tiene que ver con el análisis de tipicidad objetiva realizado sobre los dos tipos penales que integraron la falta disciplinaria, objeto de investigación y sanción. Al respecto la posición del apelante estuvo enfocada en calificar las falsedades objeto de reproche como inocuas, por inexistencia del elemento normativo "... que pueda servir de prueba...". Complementando y respaldando las motivaciones del fallador de primer grado, responde este despacho al apelante, con un interrogante. No existe aptitud probatoria en los sellos de notificación de un acto administrativo, que a la postre nos permiten corroborar o demostrar, situaciones tales como la ejecutoria e interposición oportuna de recursos?. De la misma manera no pueden servir de prueba las constancias de recibo o interposición de unos recursos, en este caso de reconsideración. Dichas constancias procesales, plasmadas sobre los memoriales impugnatorios, no nos determinan la situación temporal de los recursos?. La respuesta a estos interrogantes no puede ser otra que rechazar la presunta inocuidad que alude el recurrente de las falsedades, corroborando en su totalidad el análisis de tipicidad objetiva, presentado por el fallador a quo.

Basten las anteriores consideraciones para rechazar la impugnación presentada por el apelante, razón por la cual será objeto de confirmación total, el fallo impugnado.

En tal virtud, el Director (e) de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR, por improcedentes, las solicitudes de NULIDAD Y DECRETO DE PRUEBAS, impetradas por el procesado, ANTONIO OMAR HOYOS GALVIS, en consonancia con las razones consignadas en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. RECHAZAR, igualmente, las razones de impugnación presentadas por el sujeto procesal apelante, XXXXX XXXXX, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

TERCERO. Como consecuencia de las anteriores determinaciones, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido el 21 de noviembre de 2016, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de La Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE doce (12) AÑOS, al servidor XXXXX XXXXX, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

CUARTO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión al sujeto procesal, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002.

QUINTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

SEXTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEPTIMO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, REGISTRAR La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3o y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

POR EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL FALLO DE PRIMER GRADO PROFERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ITRC NO. 1704-01-2015-253

OCTAVO. Ejecutoriada materialmente esta decisión, libradas las comunicaciones de ley, DEVUÉLVASE el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERBERT HARBEY ROMERO RIOS
Director General (E)